

I. RELATÓRIO

LINCON HIGOR MARINI PAVON e RAIK MATEUS FERREIRA FREIRE foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 porque, supostamente, no dia 29 de janeiro de 2019, por volta de 22h15, na Rua David Fôster, Jardim Alto do Ouro Verde I, nesta cidade e comarca de Borborema, agindo em concurso de vontades e unidade de desígnios, teriam trazido consigo drogas, para fins de tráfico, consistentes em 124,77 g (cento e vinte e quatro gramas e setenta e sete centigramas) de "Cannabis Sativa L.", vulgarmente conhecida como "maconha", na forma de um tablete, além de 0,59 g (cinquenta e nove centigramas) de "Cannabis Sativa L.", vulgarmente conhecida como "maconha", na forma de um cigarro, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Defesa preliminar de LINCON HIGOR MARINI PAVON às fls. 263/277, e de RAIK MATEUS FERREIRA FREIRE à fl. 278.

A denúncia foi recebida em 16.08.2021 (fls. 280/284).

Em instrução, foram ouvidas testemunhas e um informante, e, ao final, foram interrogados os réus (fls. 377/379 e 424/430).

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a condenação de ambos os réus nos termos da denúncia (fls. 425/427).

O réu RAIK MATEUS FERREIRA FREIRE, em alegações finais orais, requereu a absolvição por falta de provas (fls. 428/429).

O réu LINCON HIGOR MARINI PAVON, nos memoriais de fls. 433/446, requereu a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Ainda subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, a aplicação do art. 33, §3º, da Lei de Drogas, a fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O feito se encontra formalmente em ordem, de modo que, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, não havendo, ainda, nulidade a sanar, passo ao exame do mérito.

A materialidade do fato está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13; auto de constatação (fls. 14/15); fotografias de fls. 16/17; laudos da natureza ilícita das substâncias apreendidas (fls. 115/116); bem como pela prova oral coligida em juízo.

Com relação à autoria, ambos os réus, em seus interrogatórios, negaram a traficância, admitindo apenas a posse do cigarro de "maconha", que seria destinado a consumo pessoal.

O réu Lincon declarou que, no dia, estava "dando uma volta de moto" com Raik. Iriam "fumar um baseado, um cigarro de maconha, que é o que encontrou comigo" (sic). Deparam-se com a viatura. Estava com a CNH vencida e não parou. Pararam nesse "baixadão", era escuro. "No local que eles me pegou lá, no bar do cabrito, eu fui parar a moto, meu amigo Raik estava com medo" (sic). Os policiais lhe atropelaram com a viatura e lhe deram voz de prisão. Os policiais disseram que eles tinham "jogado a droga". A amiga de sua tia, Ana Carla, foi junto com a sua tia no local. É usuário de "maconha". Não conhece nenhuma das pessoas que supostamente teriam "assobiado", e não havia pessoas ali. Se tinha, ninguém lhes "assobiou". Conhecia os policiais que o prenderam, eles já tinham "lhe enquadrado". Quando menor, já foi apreendido com drogas. Nada tem contra os policiais. Ganhava mais ou menos R\$ 1.500,00 ou R\$ 1.600,00 por mês. Chamou seu amigo Raik "para fumar um". Nada sabe sobre os áudios de seu celular. Inquirido sobre o conteúdo dos áudios, declarou que "chá" é "maconha". Não sabe o que é "branquinha".

O réu Raik declarou que “de tráfico não tinham nada, estavam com um beck só” (sic). Tinham apenas “um baseado” para usar. Não se recorda de pessoas paradas na calçada. Não se recorda quem chamou quem para usar drogas, mas estava sempre com Lincon. Estavam em alta velocidade quando passaram pela ponte. Estava “normal” na moto. Acha que não seria possível a Lincon dirigir com apenas com uma mão. Não se recorda de Lincon jogar algo.

A testemunha Everton declarou que estavam em patrulhamento pela área central, próximo a uma escola. O local, uma residência nas imediações, já era conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Tiveram conhecimento de uma motocicleta, de cor vermelha, fazendo transporte de droga para essa residência. Em patrulhamento, visualizaram a motocicleta. Havia alguns indivíduos sentados em uma calçada, que assobiaram, “alertando a presença da viatura para a motocicleta”. O condutor da motocicleta empreendeu fuga, não obedecendo o sinal de parada, empreendendo fuga por vários bairros. No transcurso, o condutor da motocicleta, posteriormente identificado como Lincon, retirou um objeto de sua cintura e, no intuito de arremessar em um rio, jogou o objeto, mas pela velocidade em que a motocicleta estava não teve êxito em atirar o objeto no rio. O objeto caiu nas adjacências do rio, próximo a uma ponte. A equipe continuou em perseguição à motocicleta. A motocicleta desviou de uma senhora que estava atravessando a rua, e, nisso, o condutor e o “carona” caíram ao solo. Efetuaram a abordagem. Na abordagem, encontraram um celular com Lincon, condutor, e, em sua carteira, um cigarro de maconha. Com Raik, encontraram um celular. Enquanto aguardavam o guincho, chegaram Ana Carla e Aline. Aline se apresentou como parente de Lincon. Aline tinha odor etílico. Aline foi convidada a realizar o teste do etilômetro, o que recusou. Retornaram ao local onde Lincon havia arremessado o objeto, juntamente com Ana Carla. Localizaram, próximo à ponte e às árvores, o invólucro de “maconha”. Então, deram voz de prisão a Raik e Lincon. Os indivíduos que assobiaram estavam próximos aos réus. Lincon já era conhecido dos meios policiais. Ambos admitiram a propriedade do cigarro de maconha, dizendo que seria para consumo, mas não admitiram a propriedade do tablete. Raik segurava o suporte da motocicleta, com medo de cair. Viu Lincon arremessar o tablete, e seu colega Rafael também viu. Aguardaram o veículo Guincho chegar, e só então foram até o local onde arremessada a droga. Demoraram cerca de 15 ou 20 minutos para retornar. A situação foi muito rápida. Localizou o cigarro de maconha dentro da carteira de Lincon. Rafael abordou Raik. Viu o condutor jogando a droga, Lincon. O objeto jogado era um volume em uma sacola.

No mesmo sentido, em linhas gerais, foi o depoimento da testemunha Rafael Domingos Gomes.

O informante João Carlos declarou que conhece Lincon há bastante tempo. Lincon é boa pessoa, obedece a família. Os pais nunca reclamaram de seu comportamento. Ficou sabendo, pelo pai e avô de Lincon, que o réu gastava o que ganhava em drogas. Não sabe de nenhum outro problema envolvendo Lincon.

A testemunha Aline, tia de Lincon, declarou que o réu é boa pessoa. Lincon trabalha com o pai da testemunha, e é assíduo no trabalho. Lincon respeita a família e nunca soube de nada que o desabonasse. O réu tem problemas com o uso de drogas. Não sabe se Lincon vende drogas, só sabe que é usuário. Lincon morava com a testemunha. Ele ganhava por semana.

Pois bem.

Em que pese a negativa dos réus, o conjunto probatório demonstra, com robustez, a prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas, na modalidade “trazer consigo”. De fato, o tráfico de drogas, nas modalidades “trazer consigo”, “manter em depósito”, “guardar” e “transportar”, prescinde da prova da mercancia (Jurisprudência em teses, STJ – Edição 131), bastando a demonstração de tal finalidade. A confirmar o que se expõe:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIAS SEPARADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO

CONHECIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 4. Hipótese em que a condenação da paciente pelo delito de tráfico de drogas - posse de 233.63g de cocaína e 1,35g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal - está amparada em prova suficiente (auto de apreensão, laudo de constatação, depoimentos testemunhais e conversas obtidas mediante interceptação telefônica). Logo, a pretensão de absolvição por atipicidade da conduta demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido." (STJ. HC 496.536/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Ambas as testemunhas policiais foram enfáticas ao declararem que visualizaram os réus na motocicleta, sendo alertados por terceiros ("olheiros") da aproximação da viatura e, imediatamente, empreendendo fuga. As testemunhas declararam, ainda, em depoimentos seguros e harmônicos, que visualizaram o réu Lincon arremessar o objeto posteriormente identificado (o tablete de maconha).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas assim como as demais, não tendo sido apresentada nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, o TJSP: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

No mais, pequenas divergências nos depoimentos não comprometem a sua validade e são mesmo esperadas, ante o lapso de tempo transcorrido entre o evento e a oitiva. Desencontros pontuais, periféricos, são compreensíveis, pois naturais falhas de memória e a rapidez dos fatos influem na percepção e retenção dos acontecimentos secundários. Naquilo que é dotado de centralidade (o alerta por terceiros, a conduta de Lincon de dispensar o tablete posteriormente localizado), os depoimentos de Everton e Rafael são harmônicos, e nada há, nos autos, a indicar que queiram prejudicar os réus, incriminando-os falsamente.

Outrossim, em que pese a Defesa alegar que o tablete de "maconha" foi encontrado "cerca de uma hora depois do término da perseguição", a vinculação dos réus com o objeto material do crime é inequívoca. A testemunha Everton afirmou que, entre a abordagem e o encontro da droga que Lincon dispensara, passaram-se cerca de 15 ou 20 minutos, e não uma hora. Ademais, reitero que ambas as testemunhas visualizaram o ato de Lincon de jogar o entorpecente, encontrando-o, logo após, exatamente no lugar em que fora dispensado.

Assim, diante de todo o conjunto probatório, suficiente concluir que os réus, de fato, traziam consigo drogas, para fins de tráfico, evadindo-se ao avistarem a viatura e receberem o alerta (assobios) de terceiros, abordados logo após, em situação de flagrante (art. 302 do CPP), com posterior condução ao local onde apreendida e finalmente localizada a droga dispensada por Lincon (além de localizada a droga que estava na carteira de tal réu).

Não há falar em encontro fortuito de entorpecentes em via pública. As testemunhas, efetivamente, visualizaram o réu Lincon (que estava junto com o réu Raik) dispensar o entorpecente.

Desse modo, não cogito de absolvição de nenhum dos réus por insuficiência de provas, tendo em vista que o conjunto de provas autoriza, com segurança, a prolação de édito condenatório, acima da dúvida razoável. Não remanesce dúvida a favorecer os réus.

Muito embora ambos os réus tenham afirmado que são usuários e que a "maconha" presente na carteira de Lincon se destinado ao uso compartilhado, não há como

afastar o delito previsto no art. 33, caput, da LD.

Com efeito, é firme o entendimento de que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, bastando, para a incursão no crime de tráfico, que o agente incorra em qualquer das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, como ocorreu no caso.

Descabido cogitar de desclassificação, em relação a ambos, para o delito do art. 28 do LD.

Conforme preceitua o art. 28, §2º, da Lei de Drogas, para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, há de se atentar à: a) natureza e quantidade da substância apreendida; b) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação; c) às circunstâncias sociais e pessoais; bem como e) à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em concreto, a “Cannabis Sativa L.”, em forma de tablete, alcançava o montante expressivo de 124,77 g, quantidade incompatível com uso episódico alegado pelos réus.

Apenas como referencial, cumpre trazer à baila a tabela esquemática presente no Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre o Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, elaborado pela Secretaria do Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná no ano de 2014, citada no julgamento do RE 635.659, Repercussão Geral, de Rel. do Min. Gilmar Mendes (cujo objeto é a análise da constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006).

O estudo técnico mencionado aponta, apenas como um norte que a quantidade média diária para uso individual de “maconha” é de 2,5 gramas, amparado na Portaria nº 95/96 – Portugal, sugerida como parâmetro pela SENAD/MJ.

Também o Min. Celso de Mello, no HC 144.716/SP, julgado em 16 de outubro de 2017, apontou tal estudo como parâmetro exemplificativo para a elucidação da destinação precípua de entorpecentes.

No caso dos autos, veja-se que a “maconha” apreendida supera, em muito, a quantidade média para uso diário, circunstância que, à luz dos demais elementos, acima minudenciados, reforça a tese acusatória de destinação dos entorpecentes à traficância.

Demais disso, o local e as condições em que a ação se desenvolveu também pesam em desfavor dos réus. A uma, porque as testemunhas noticiaram que o local em que avistada a motocicleta era conhecido ponto de tráfico da comarca; a duas, porque tanto Rafael quanto Everton afirmaram que os réus foram avisados da proximidade da viatura, circunstância a corroborar o fato de que a droga era destinada a terceiros, no âmbito de traficância ali exercida.

E mais, quanto às circunstâncias sociais e pessoais de ambos não há indicativos firmes de que os réus exercessem trabalho lícito à época do flagrante, a partir do qual pudessem amealhar recursos para adquirir toda a quantidade de drogas apreendidas, especificamente o “tablete” de maconha (de 124,77 g).

Não bastasse, o relatório de fl. 209 aponta a existência de vários áudios, no “whatsapp” de Lincon, que denotam, inequivocamente, atividade de traficância, e não apenas uso. Como exemplo, em um dos áudios, o réu Lincon diz que está indo para Itápolis comprar entorpecentes, mas o vendedor não tem “chá” nem “branquinha”, presumivelmente, “Cannabis Sativa L” ou “cocaína” (valendo notar que, em seu interrogatório, disse o réu ser usuário apenas de “maconha”). Em outro áudio, consoante relatório de fl. 209, Lincon diz que está aguardando receber meio quilo de “maconha”, quantidade incompatível com a destinação exclusiva ao uso.

Constatada a prova da materialidade e da autoria, quanto a ambos, passo ao exame da tipicidade.

Nesse particular, ambos os réus eram menores de 21 anos à data do fato (30/01/2019), razão pela qual, oportunamente, observar-se-á, se for o caso (Súmula 231 do STJ), a atenuante prevista no art. 65, I, do CP. Raik é nascido em 19/10/2000, e Lincon, em 09/02/1999 (fls. 418/421).

Inadmissível a aplicação da atenuante da confissão (Súmula 630 do STJ).

Lado outro, ambos os réus pugnaram pela aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º, do Código Penal.

Com efeito, referido dispositivo prevê que, “§ 4o Nos delitos definidos no caput e

no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços (...), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”. A análise das certidões de fls. 419/420 e 423 demonstra que ambos os réus são primários.

No entanto, a análise do caderno processual denota ser a benesse aplicável somente a Raik.

De fato, não há elementos de prova de que Raik se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Consoante definido pelo STF, 2ª Turma, no HC 154.694/SP, para fins do art. 33, §3º, da Lei de Drogas, milita em favor do réu a presunção de que é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus de provar o contrário é do Ministério Público, o que não ocorreu, no presente caso, quanto a Raik.

Ademais, e não olvidando a divergência jurisprudencial, na linha do entendimento do STF, a quantidade de droga, isoladamente, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (RHC 138715/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23.05.2017, Informativo 866).

Ainda dentro dessa linha de considerações, a meu ver, não assiste razão ao Ministério Público quanto à alegação de não ser cabível o privilégio a Raik pois “existem nos autos informações anônimas sobre o tráfico no local desde 17 de junho de 2016”. Tais delações apócrifas não se prestam a demonstrar que Raik, ali e com certa reiteração, exercesse a traficância.

Diante de todos esses fundamentos, é imperativa a aplicação, em favor de Raik, do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Conclusão diversa se aplica a Lincon.

O relatório de investigação de fl. 209, calcado nas mídias de áudio presentes no celular de Lincon, demonstram que realmente faz da criminalidade seu meio de vida. A testemunha e informante ouvidas a convite da defesa, no item, foram meramente abonatórias e seus depoimentos não têm o condão de afastar o cenário fático indicado pelos áudios enviados pelo próprio réu por meio do seu aparelho telefônico.

Conforme tais áudios apontavam, o réu, mais de uma vez, adquiria quantidade expressiva de drogas (como o meio quilo relatado no áudio). Nessa quadra, na interpretação da causa de diminuição de pena, deve-se atentar para o elemento teleológico, conforme art. 5º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O objetivo legal foi o de beneficiar, com a sensível redução da pena, aquele agente que, pela primeira vez, se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade (de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de drogas, seja suficiente para a reprovação do comportamento). Afinal, rememore-se que a Constituição Federal possui mandato explícito de criminalização, com maior rigor penal, do tráfico de drogas, conforme art. 5º, XLIII.

No caso dos autos, descabe cogitar que Lincon, ante o teor das conversas contidas em seu celular, houvesse adquirido as drogas apreendidas em uma incursão inédita no meio criminoso.

Logo, afasto, para o réu Lincon, a benesse do art. 33, §4º, da LD.

Em razão do exposto, suficientemente comprovadas a existência e a autoria do crime pertinente ao fato descrito na denúncia, e não verificando a ocorrência de causa ou circunstâncias que excluam o crime ou isentem os réus de pena, é impositiva a responsabilização penal.

Passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, art. 42 da Lei 11.343/2006 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Dosimetria e individualização da pena

Do réu LINCON HIGOR MARINI PAVON

Na primeira fase, convém rememorar o art. 42 da Lei de Drogas, segundo o qual “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.

Em atenção às circunstâncias do crime, inexistem motivos para impor a fixação da sanção-base acima do mínimo legal.

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

O réu não possui maus antecedentes.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos.

Os motivos que a levaram a cometer o delito são normais à espécie.

As consequências foram normais.

Não há falar em comportamento da vítima (crime vago).

Portanto, estabeleço a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Na segunda fase do cálculo, está presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal).

Não há agravantes.

De rigor observar, porém, que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Portanto, nesta fase, mantenho a pena no patamar anterior.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não incidem causas de aumento, tampouco é cabível a aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, conforme fundamentado anteriormente.

Face a tanto, fixo a pena final em 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Do réu RAIK MATEUS FERREIRA FREIRE

Na primeira fase, convém rememorar o art. 42 da Lei de Drogas, segundo o qual “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.

Em atenção às circunstâncias do crime, inexistem motivos para impor a fixação da sanção-base acima do mínimo legal.

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

O réu não possui maus antecedentes.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos.

Os motivos que a levaram a cometer o delito são normais à espécie.

As consequências foram normais.

Não há falar em comportamento da vítima (crime vago).

Portanto, estabeleço a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Na segunda fase do cálculo, está presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal).

Não há agravantes.

De rigor observar, porém, que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Portanto, mantenho a pena, nesta fase, no patamar anterior.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não incidem causas de aumento.

Cabível a aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Quanto ao aspecto, a redução se impõe no máximo patamar, isto é, 2/3, não se visualizando circunstâncias excepcionais que imponham a modulação do redutor em parâmetro mais prejudicial. Portanto, diminuo a pena em 2/3 e a fixo, definitivamente, em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no mínimo legal.

Disposições comuns

Regime inicial

Para a fixação do regime inicial, cumpre observar os critérios do art. 33, §§2º e 3º e art. 59, todos do Código Penal.

No caso dos autos, ante a primariedade dos réus e ausência de circunstâncias judiciais negativas, e considerando o quantum das penas, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO para Lincon (art. 33, §2º, "b", do CP, e ABERTO, para Raik (o que faço com fundamento no art. 33, §2º, alínea "c", do CP).

Eventual detração a que façam jus deverá ser examinada pelo Juízo da Execução (art. 66, III, "c", da LEP), conforme entendimento sedimentado da jurisprudência do STJ (HC 443.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Quanto a Lincon, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP. Ainda, é também incabível a suspensão condicional da pena, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 77 do CP.

Já quanto a Raik, impositiva a substituição.

Quanto à matéria, no julgamento do HC 97.256, o Tribunal Pleno do STF, por maioria, considerou inconstitucionais os dispositivos da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) que vedam a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Posto isso, o réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º, segunda parte, e §4º, do CP), consistentes em:

a) prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (art. 46, §4º, do CP); e, b) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo (art. 45, §1º, do CP), em favor de entidade pública ou privada com destinação social, conforme definir o Juízo das Execuções Criminais.

Diante da substituição, resulta prejudicada a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Art. 387, inciso IV, do CPP

Em função de o delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito passivo indeterminado, incabível a fixação de valor para a reparação civil de ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para:

a) CONDENAR o réu LINCON HIGOR MARINI PAVON, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de reclusão de 5 (cinco) anos, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal;

b) CONDENAR o réu RAIK MATEUS FERREIRA FREIRE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão; e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal; substituída, a pena corporal, por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada (art. 46, §4º, do CP); e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo (art. 45, §1º, do CP), em favor de entidade pública ou privada com destinação social, conforme definir o Juízo das Execuções Criminais. Na hipótese de descumprimento injustificado (art. 44, § 4º do Código Penal), deverá o réu iniciar o cumprimento da pena corporal no regime ABERTO (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

"Status Libertatis": concedo a ambos os réus o direito de recorrerem em liberdade, porquanto ausentes os requisitos, pressupostos e condições para decretação de prisão preventiva.

Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Transitada em julgado:

a) Oficie-se ao IIRGD;

b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos dos réus, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;

c) Intimem-se para pagamento da pena de multa.

Decreto o perdimento do celular do réu Lincon em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, uma vez que utilizado para a concretização da prática delitiva.

Por outro lado, não comprovada a utilização do aparelho celular de Raik para o tráfico de drogas, defiro sua imediata restituição ao réu.

Expeça-se certidão de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Condeno os réus ao pagamento das custas (art. 804 do CPP). Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Borborema, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA